

1500285-65.2021.8.26.0653

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MARINA SILOS DE ARAUJO

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... área da Cohab 5, visando coibir o tráfico de drogas no local. Informam que em virtude de várias denúncias em desfavor de MICHEL DOUGLAS FARIA, vulgo "peixinho", resolveram monitorar o local. Os policiais visualizaram quando TIAGO APARECIDO DA SILVA, também conhecido dos meios policiais por ser usuário de drogas, se aproxima de MICHEL próximo a residência dele, faz um contato e logo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande do Sul

Foro de Vargem Grande do Sul

1ª Vara

Av. Walter Tatoni, nº 343, ., Vila Santana - CEP 13880-000, Fone: (19) 3641-2004,

Vargem Grande do Sul-SP - E-mail: vgdosul1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500285-65.2021.8.26.0653

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3032631/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 17464875 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

TIAGO APARECIDO DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Aos 11 de abril de 2022, às 14:35h, na sala de audiências da 1ª Vara do Foro de Vargem Grande do Sul, Comarca de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMA. Juíza de Direito Dra. MARINA SILOS DE ARAUJO, presente o Promotor de Justiça, DR. LEONARDO MEIZIKAS, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, sendo esta realizada pelo sistema de videoconferência, com a anuência de todos e sem prejuízo, nos termos do Comunicado nº 284/2020 da Corregedoria Geral da Justiça e Provimento nº 2.557/2020 do Conselho Superior da Magistratura. Aberta a audiência, verificou-se a presença do acusado TIAGO APARECIDO DA SILVA e de seu defensor, DR. DONIZETE JOSÉ CARLOS PEREIRA - OAB/SP 341.524. AUSENTES as testemunhas arroladas pela acusação. Iniciados os trabalhos, foi dada a palavra à defesa para responder a acusação, tendo dito o seguinte: "MMA. Juíza, a denúncia não deve ser recebida, eis que o acusado não praticou o crime que

lhe foi imputado". Em seguida, pela MMA. Juíza foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Presentes indícios de autoria e materialidade, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra TIAGO APARECIDO DA SILVA". Ato seguinte, tomou-se o interrogatório do acusado, por intermédio de gravação audiovisual. Dada a palavra ao representante do Ministério Público, requereu a desistência da oitiva das testemunhas ausentes. Pela MMA. Juíza foi dito que: "Homologo a desistência da oitiva das testemunhas ausentes requerida pelo representante do Ministério Público. Dou por encerrada a instrução probatória e concedo a palavra às partes para apresentação de alegações finais. Após, pela MMA. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. TIAGO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº. 11.343/06 porque, no dia 21 de abril de 2021, por volta das 18h10, na Avenida Antônio Bolonha, n. 291, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de uso pessoal, 01 (uma) porção de cocaína na forma de crack, pesando cerca de 0,15g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Dispensado, no mais, o relatório (Lei n. 9.099/95, artigo 81, § 3º). DECIDO. A pretensão punitiva procede, eis que materialidade e autoria do delito imputado ao réu restaram seguramente demonstradas, conforme se extrai do Termo Circunstanciado de Ocorrência (fls. 01/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 07), do laudo pericial de fls. 104/106, bem como pela prova oral produzida. Na Delegacia de Polícia o acusado assim afirmou: "Que é usuário de "crack" há muitos anos, e na data de hoje, como de costume foi até a Cohab 6, onde reside "peixinho", com o intuito de comprar uma pedra de "crack". Como "peixinho", não estava em sua residência, o declarante permaneceu nas imediações até a chegada dele. Não demorou muito tempo, "peixinho", chegou no local com seu cachorro, e já foi perguntando ao declarante: "Quantas você quer?", tendo o declarante informado que queria apenas uma. "Peixinho", foi até um poste, mexeu no local, e colocou as pedras de "crack" na boca, depois se aproximou do declarante, pegou uma que estava na boca e entregou a ele. O declarante pegou a pedra de "crack", colocou no interior de sua boca, realizou o pagamento com cinco notas de dois reais, e deixou o local, se dirigindo a rodovia. Há poucos metros do local da compra, o declarante foi abordado por uma viatura policial, e de pronto confessou que havia acabado de comprar a pedra de "crack" de "peixinho", pela importância de R\$ 10,00 (dez reais)." Ouvido em Juízo, sob o manto do contraditório e assegurada a ampla defesa, Tiago ratificou a confissão extrajudicial. Disse que trazia a droga consigo para o próprio consumo e que é usuário de drogas desde os 17 anos de idade. Com efeito, a confissão segura e espontânea do réu restou confirmada pelos demais elementos de prova. Na Delegacia de Polícia, os policiais militares Paulo César Emiliano e Silas Emanuel da Silva, de forma harmônica e coerente, relataram que "encontravam-se em serviço e realizavam patrulhamento ostensivo de rotina pela área da Cohab 5, visando coibir o tráfico de drogas no local. Informam que em virtude de várias denúncias em desfavor de MICHEL DOUGLAS FARIA, vulgo "peixinho", resolveram monitorar o local. Os policiais visualizaram quando TIAGO APARECIDO DA SILVA, também conhecido dos meios policiais por ser usuário de drogas, se aproxima de MICHEL próximo a residência dele, faz um contato e logo em seguida deixa o local. Os policiais conseguiram abordar TIAGO, no acesso de terra, no prolongamento da Avenida Ney Fernandes Bolonha, o qual foi submetido a busca pessoal e encontrado no interior de sua boca, uma pedra de "crack", devidamente embalada em plástico branco. TIAGO ao ser interpelado sobre a porção de "crack", confessou que havia acabado de adquirir de MICHEL, pela importância de R\$ 10,00 (dez reais). De forma minuciosa, TIAGO esclareceu que é usuário de "crack" há muito tempo, e que sempre adquire drogas de MICHEL. Diante das circunstâncias, TIAGO foi convidado a acompanhar os policiais, sendo neste ato solicitado apoio de outra viatura policial. MICHEL foi abordado na rua adjacente a sua residência, ou seja, a Rua Antonio Bertololoto e submetido a busca pessoal, porém nada de ilícito encontrado em seu poder. Os policiais ao informarem que haviam visto MICHEL momentos antes realizando a venda de drogas a pessoa de TIAGO, ele acabou confessando que realmente estava realizando o tráfico". Lado outro, o laudo pericial revelou que a substância apreendida em poder de Tiago é cocaína. Portanto, não há dúvidas de que

o réu praticou a conduta descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Anoto, por oportuno, que o fato de ser mero usuário de drogas não afasta a responsabilidade criminal do réu, tampouco há se falar em fato atípico, em aplicação do princípio da insignificância ou, ainda, em inconstitucionalidade da norma (artigo 28 da Lei n. 11.343/06). A subsistência do caráter criminoso da conduta se justifica pela lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade e saúde públicas, que preponderam sobre o direito individual à inviolabilidade da intimidade e da vida privada que, tal como todos os demais direitos individuais, não são absolutos. O tipo penal seria inconstitucional se punisse o consumo de drogas, que, realmente, causa mal à saúde do próprio usuário. Entretanto, a lei não pune o consumo da droga. O legislador cuidou de incriminar apenas o ato de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É que, ao praticar qualquer das condutas previstas no artigo 28, caput da Lei n. 11.343/06, o agente vulnera o bem tutelado na norma incriminadora, qual seja, a incolumidade e a saúde pública. Não se trata de conduta insignificante. Em casos como o dos autos, não se pode sequer mencionar que o tipo padece de inconstitucionalidade por violar o direito à intimidade. Isso porque, além de tal direito não se sobrepor à saúde pública, não se falar em intimidade de os réus traziam consigo a droga em via pública. Deveras, não há se falar em direito à intimidade se o agente é flagrado praticando a conduta publicamente. Pensar o contrário seria afirmar que, v.g., também não configura crime a prática de ato obsceno. Sobre a razão da incriminação das condutas previstas no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi assim expõem: "A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que a conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fator decisivo da difusão dos tóxicos." (Lei de Drogas Anotada. Lei n. 11.343/2006. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 2008, p. 46). Com efeito, todo delito associado a entorpecentes constitui risco potencial para a sociedade, porque todos eles vulneram o bem tutelado na norma. Não por outro motivo, o artigo 28 da Lei n. 11.343/06 cuida de infração de mera conduta, sendo prescindível perigo concreto ao bem jurídico, vale dizer, para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O perigo é presumido em caráter absoluto, bastando, para a configuração do crime, que a conduta seja subsumida em um dos verbos previstos. No mesmo sentido: "...Neste ponto não há de ser reconhecida, ainda, a alegada inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, em virtude do princípio da alteridade. Alega o apelo defensivo que como o porte de drogas para uso não afetaria esfera jurídica outra além da do próprio agente ativo do tipo, o usuário, tal conduta não poderia ser penalmente tipificada e o respectivo artigo seria, por conseguinte, materialmente inconstitucional. Todavia, tal alegação não procede. Não se pode perder de vista que o que é criminalizado não é o uso de entorpecente, mas sim o seu porte, que tem reflexo na coletividade e na saúde pública, bens jurídicos relevantes que extrapolam a esfera individual do usuário. Apesar das discussões na sociedade civil acerca da descriminalização de drogas, ainda é adotado, como escolha política de nosso legislativo, o modelo de tipificação penal do porte e venda de entorpecentes como meio de frear a disseminação de tais substâncias, em virtude de seus efeitos danosos que se espraiam muito além dos usuários por toda a sociedade. Nesse sentido, o Desembargador Ary Belfort, como relator da Apelação Criminal nº 211.041-3 (Mairiporã, 4ª Câmara Criminal, 9-10-1996) ainda na vigência da Lei 6.368/76, mas de forma completamente

aplicável à legislação em vigor -, já pontuou com muita percuciência que a inconstitucionalidade do porte de drogas ' parte do pressuposto errado de que haja punição para o utente. Mas não há isso em nosso país e em nosso sistema penal-típico. Usar, no Brasil, não infringe a lei especial; nem lei alguma; o que proíbe a Lei é adquirir, guardar ou trazer consigo para uso próprio. Portanto, assegura sua liberdade individual, uso o tóxico que quiser, tanto quanto puder. Mas não guarde, não transporte consigo. Pois nestas figuras está, precisamente, o perigo à

coletividade que sabiamente a Lei quis evitar" (AC 0002009-72.2012.8.26.0564, 16ª Câmara de Direito Criminal, TJ/SP, Rel. Otávio de Almeida Toledo, 04.02.2014). Mas não é só. Reiteradamente, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já reconheceram o caráter criminoso da conduta descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Nesse sentido: "O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a situação jurídica do delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, afirmou a natureza delituosa da conduta do usuário de drogas, não havendo se falar em abolitio criminis ou infração penal sui generis, muito embora haja a despenalização do delito (RE 430.105 QO/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJe de 26.4.2007). Assim, reconhecida a conduta de posse de drogas como crime, não há constrangimento ilegal em sua utilização para a valoração negativa dos antecedentes." (STJ, Habeas Corpus nº 216.667/SP, 5ª Turma, Rel. Marilza Maynard, 20/06/2013). "HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. REINCIDÊNCIA. COMETIMENTO ANTERIOR DO CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA DESPENALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. NÃO CONHECIMENTO. 1. As instâncias ordinárias adotaram fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 13 porções de crack (109 g) e 4 porções de maconha (44 g) - (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006). 2. Esta Corte, na esteira do posicionamento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n.º 430.105-9/RJ), consolidou o entendimento de que, com o advento da Lei n.º 11.343/2006, não ocorreu a descriminalização (abolitio criminis) da conduta de posse de substância entorpecente para consumo pessoal, mas, tão somente, a mera despenalização, pelo fato de o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 não impor pena privativa de liberdade ao usuário de drogas. 3. Comprovada a existência de condenação definitiva anterior pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, haja vista que o paciente não preenche os requisitos legais, porquanto é reincidente. 4. Inviável fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, por tratar-se de réu reincidente (art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal). 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos submete-se à regência do art. 44 do Código Penal, segundo o qual só faz jus ao benefício legal o condenado a pena inferior a 4 anos. Na espécie, tendo a reprimenda final alcançado 6 anos de reclusão, não é possível a pretendida substituição. 6. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 299.988/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 17/09/2015). "HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. COMETIMENTO ANTERIOR DO CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA DESPENALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. Esta Corte, na esteira do posicionamento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n.º 430.105-9/RJ), consolidou o entendimento de que, com o advento da Lei n.º 11.343/2006, não ocorreu a descriminalização (abolitio criminis) da conduta de posse de substância entorpecente para consumo pessoal, mas, tão somente, a mera despenalização, pelo fato de o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 não impor pena privativa de liberdade ao usuário de drogas. 3. Comprovada a existência de

condenação definitiva anterior pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, haja vista que o paciente não preenche os requisitos legais, porquanto é reincidente. 4. Condenado o paciente à pena de 5 anos de reclusão, inviável a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. 5. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 266.827/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 11/04/2014). Por fim, saliento que, a despeito da existência do recurso Extraordinário n. 635.659, é certo que tal julgamento ainda não foi concluído, ou seja, o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu a respeito da constitucionalidade ou não do artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Assim, e tendo em vista que, até que, eventualmente, seja declarada a inconstitucionalidade, as normas são presumidas constitucionais, a conduta praticada pelo réu é típica e gera responsabilidade criminal. Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação ou justificara a pretendida absolvição sumária, mostrando-se a prova colhida segura e absolutamente suficiente para a condenação. Por reputar mais adequada, aplico ao réu a sanção consistente em advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, nos termos do artigo 28, I, da Lei n. 11.343/06. Desnecessária a imposição de outra medida. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na denúncia e, como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, CONDENO TIAGO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, à sanção prevista no inciso I da Lei 11.343/06, qual seja, ADVERTÊNCIA sobre os efeitos da droga. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as devidas comunicações. Dou esta sentença por publicada em audiência, saindo as partes intimadas. Cumpra-se" Indagadas as partes a respeito de eventual recurso, pelo réu e por seu defensor foi dito que não tinham interesse em recorrer da sentença, motivo pelo qual renunciaram ao prazo recursal. O representante do Ministério Público também afirmou não haver interesse recursal, tendo em vista que a pretensão punitiva foi acolhida da forma como requerido. Por fim, pela MMA. Juíza foi proferida a seguinte decisão: "Diante das manifestações das partes quanto à ausência de interesse recursal, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado. Bem por isto, nesta oportunidade advirto o réu quanto aos efeitos nocivos da droga, de modo que resta cumprida a sanção que lhe foi imposta, extinguindo-se a punibilidade. Nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB/SP, arbitro honorários ao Dr. Donizete José Carlos Pereira no valor máximo previsto na tabela para sua atuação neste feito. Expeça-se imediatamente a correspondente certidão. Após, realizadas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos". Nada mais. Eu, GUSTAVO RESENDE DOS SANTOS, digitei.